

1502979-55.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Furto qualificado - Prisão na posse da res furtiva logo após o crime - Álibi não comprovado - Circunstâncias que sugerem a autoria do furto - Confissão informal confirmada pelos policiais - Desclassificação para receptação - Impossibilidade; Furto qualificado - Rompimento de obstáculo - Emprego de violência contra o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1502979-55.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502979-55.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

KARINA DE OLIVEIRA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

ALEX SANDRO DOS SANTOS, MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS, DANILO DIAS ROCHA e KARINA DE OLIVEIRA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 04h30, na Rua Guaimbe, nº 365, Mooca, nesta cidade e comarca da Capital/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 09 (nove) garrafas de whisky, marca Red Label, avaliadas em R\$75,00 (setenta e cinco reais) cada; 01 (uma) garrafa de whisky, marca Jack Daniels, avaliada em R\$150,00 (cento e cinquenta reais); 01 (uma) garrafa de whisky, marca Blue Label, avaliada em R\$700,00 (setecentos reais); 02 (duas) garrafas de whisky, marca Chivas Regal, avaliadas em R\$140,00 (cento e quarenta reais) cada; 01 (um) garrafa de whisky, marca Chivas Regal Royal Salute, avaliada em R\$150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) garrafa de bebida alcoólica, marca Jack Daniels, avaliada em R\$400,00 (quatrocentos reais), 02 (duas) garrafas de bebida alcoólica, marca Red/Blue, avaliadas em R\$1.000,00 (mil reais) e (03) três garrafas de vodka, avaliadas em R\$1200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes a empresa vítima Brasa e Beer, representada por Antonio Carlos Domiciano.

A denúncia foi recebida (fls.213/214), os réus foram citados e notificados (fls.215, 263,265 e 273) e apresentaram Resposta à Acusação (fls. 278/279 - Alex Sandro, Maria da Penha e Danilo e 305 - Karina).

A fls. 335/336 e 376 determinou-se o cumprimento da ordem de Habeas Corpus que determinou a soltura de Maria da Penha Pereira dos Santos, Danilo Dias Rocha e Alex Sandro dos Santos.

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 280/281 e 307), não sendo o caso de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia 11 de janeiro de 2021 e em continuidade para 17 de agosto de 2021 e 09 de agosto de 2022, durante a qual, decretada a revelia dos réus MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS (fls. 425), DANILO DIAS ROCHA e ALEX SANDRO DOS SANTOS (fls. 548), foram ouvidos o representante da vítima, as testemunhas e, ao final, a ré KARINA DE OLIVEIRA SILVA foi interrogada (fls. 425, 548 e 574/577).

Finda a instrução, em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

A Defesa de KARINA DE OLIVEIRA SILVA, oralmente, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pela fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial diverso do fechado conforme súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ e direito de apelar em liberdade.

A Defesa dos réus DANILO DIAS ROCHA e MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS em memoriais escritos (fls. 564/573) pugnou pela absolvição dos acusados com fundamento no artigo 386, III, V ou VII do CPP. Subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea, reconhecimento da tentativa, fixação de regime inicial diverso do fechado e consideração do tempo de prisão preventiva.

A Defesa do réu ALEX SANDRO DOS SANTOS (fls. 581/587), pugnou pela absolvição por insuficiência de provas de ter concorrido para o crime, com fundamento no artigo 386, II, V, do CPP ou a absolvição por falta de provas, artigo 386, VII, CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pelo reconhecimento da tentativa. É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente em relação aos acusados DANILO, MARIA DA PENHA e ALEX SANDRO e improcedente em relação à acusada KARINA.

A a materialidade delitativa restou devidamente comprovada pelo Auto de prisão em Flagrante (fls.01), Termos de Depoimento e Declarações (fls. 02/03 e 04), Boletim de Ocorrência (fls.09/13), Autos de Exibição, Apreensão e Entrega (fls.14/15 e 16), Fotografias (fls. 74/75), Relatório Final (fls, 148/149), Laudos Periciais (fls. 393/397 e 398/408) e Resposta ao Ofício encaminhado ao estabelecimento comercial Templo Bar e Lanchonete Ltda (fls. 536).

Já a autoria, especialmente em vista da prova oral produzida nos autos, restou devidamente comprovada em relação aos acusados DANILO, MARIA DA PENHA e ALEX SANDRO, mas não em relação à acusada KARINA, senão vejamos.

ALEX SANDRO DOS SANTOS na delegacia, exerceu seu direito de permanecer em silêncio (fls. 05). Em juízo, teve sua revelia decretada e não foi interrogado.

MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS, na fase investigativa exerceu seu direito de permanecer em silêncio (fls. 06). Em juízo, teve decretada a sua revelia e não foi interrogada.

DANILO DIAS ROCHA manifestou o desejo de permanecer em silêncio em solo policial, no que foi respeitado (fls. 07). Em juízo teve sua revelia decretada e não foi interrogado.

A acusada KARINA DE OLIVEIRA SILVA, por sua vez, em solo policial (fls. 08), negou os fatos. Disse que estava nas proximidades do local dos fatos com Maria e ia chamar um UBER para irem embora; indagada se a ligação para o aplicativo foi feita de seu aparelho celular, disse que não, que ela fora feita do aparelho celular de "Jaca" (sic), companheiro de Maria e um amigo dele que estavam furtando um estabelecimento comercial, sendo que as duas permaneceu (sic) nas proximidades.

Nunca foi presa ou processada. Não tem filhos. Indagado do porquê ter dito que não conhecia nenhum dos indivíduos que estavam no interior do estabelecimento, respondeu que disse isso por ter ficado com medo.

Em juízo, KARINA novamente, negou os fatos. Esclareceu que estava em casa quando sua colega, Maria, ligou e a chamou para ir num bar chamado Templo para curtir um pagode. Bebeu no local e não sabia nada do que ia acontecer. Depois de sair do bar Templo encontrou com os rapazes, Alex e Danilo, que eram conhecidos da Maria. Daí se encontraram na rua e quando viu tinha uma viatura vindo e não sabia o que tinha acontecido, mas nem conseguia dizer nada porque tinha bebido. Os policiais mandaram parar se não iam atirar. Continuou andando porque não entendeu que era consigo. Mas daí os policiais insistiram e então obedeceu. Perguntou o que estava havendo e os policiais disseram que estavam todos presos. Os rapazes disseram que era problema deles, que ela e a Maria não tinham nada com isso. Saiu para curtir, não para ofuscar o brilho de alguém que está ali trabalhando, jamais.

Sua Folha de Antecedentes (fls. 73 e 129/131) e a Certidão do Distribuidor Criminal (fls. 138/139) foram juntadas aos autos e na primeira parte de seu interrogatório esclareceu que tem 22 anos de idade. É solteira e não tem filhos. Estudou até o 1º ano do ensino médio. Parou de estudar com 17 anos, porque foi trabalhar. Na data dos fatos estava trabalhando e atualmente está sem trabalho. Trabalhava de vendedora de painéis. Tinha uma loja no Brás. Está sem renda. Mora com os pais, em casa própria. Nunca foi processada antes.

Desta feita, de acordo com a versão da acusada KARINA ela apenas encontrou com a colega MARIA DA PENHA, com quem bebeu cerveja no dia e, posteriormente, foram encontrar com os acusados ALEX SANDRO e DANILO conhecidos de MARIA, quando então houve a abordagem policial.

Antonio Carlos Domiciano, representante da vítima, esclareceu quando ouvido em juízo que na data dos fatos o alarme de segurança disparou e acionou a equipe da empresa de segurança que se dirigiu ao local e pegou os acusados saindo do estabelecimento na posse dos bens descritos na denúncia. Inicialmente foi para o estabelecimento e pode constatar que faltavam vários itens no comércio. A porta balcão foi arrombada. Arrancaram a fechadura da porta de vidro. Os acusados subiram por uma janela pela parte de cima do imóvel vizinho, com altura de cerca de três metros e arrombaram o local. Foram levadas várias garrafas de whisky, vodka, duas garrafas de 5 Litros, grandes no valor aproximado de R\$ 1.800,00 cada. Parte dos bens foram recuperados. Para arrumar o estabelecimento gastou cerca de R\$ 800,00. Tinha câmera de vídeo no local mas não se recorda se estava gravando e se chegou a ver imagens dos autores do crime.

Ouvido o policial militar, Rosemberg Aparecido Francesquete como testemunha, disse que estava em patrulhamento de rotina com o parceiro quando foram acionados via COPOM sobre ocorrência de furto em um bar. Chegando no local, encontraram os quatro acusados na frente do bar com mochilas e bolsas e efetuaram a abordagem. Disse que informalmente os homens e uma das moças confessaram a prática delitiva. Eles tinham bebidas nas bolsas e mochilas. Os acusados escalararam por uma parede ao lado do estabelecimento e entraram mediante arrombamento de uma janela. Houve apreensão de alicate, chave de fenda e cordas. Eles tinham bebidas alcoólicas dentro das mochilas, whisky e vodka, cerca de 12 garrafas. A vítima compareceu na delegacia e apresentou uma filmagem e reconheceu os acusados. Reconheceu a acusada Karina em audiência como uma das pessoas detidas, mas não se recordou se ela ou a outra acusada, confessou a prática delitiva. Os quatro acusados estavam juntos em frente ao estabelecimento. Um homem e uma moça carregavam os objetos furtados e os outros dois os acompanhavam. Não havia mais pessoas ali no local. Os produtos eram muito pesados e por isso acredita que eles teriam apoio para fuga. Eles estavam todos juntos em frente ao bar citado na denúncia. Nenhum deles ofereceu resistência quando da abordagem. Karina não aparentava ter bebido.

Xu Yi Xiong, testemunha, policial militar, disse que foram acionados via COPOM para atender ocorrência de furto em andamento. Chegando ao local encontraram os quatro acusados, sendo que dois deles portavam, cada qual, uma mochila e uma sacola contendo bebidas alcoólicas, produtos do estabelecimento. Eles confessaram a prática delitiva e foram conduzidos para a delegacia. Havia duas mulheres na

ocasião, sendo uma delas, a acusada, Karina, reconhecida em audiência como uma das autoras do delito. A acusada confessou a prática delitiva. Não se recorda sobre sinais de arrombamento. A vítima reconheceu as bebidas apreendidas. A acusada Karina não ofereceu resistência. Não se recorda se ela aparentava ter bebido. A testemunha não viu as filmagens do crime, mas acredita que o dono do estabelecimento as entregou na delegacia.

Essas são as provas colhidas e diante delas a condenação se impõe.

Relativamente aos acusados ALEX SANDRO e DANILO não há dúvida de que estavam juntos no estabelecimento que foi palco do furto, seja pelo fato de estarem no local quando abordados pela polícia, seja porque a própria acusada KARINA afirmou que saiu com MARIA DA PENHA e foram posteriormente ao encontro dos dois rapazes que estavam juntos realizando o furto, como soube posteriormente.

Ainda, de acordo com a denúncia, foram pegos com mochilas e sacolas dentro das quais estavam os objetos subtraídos.

Já em relação à acusada MARIA DA PENHA, a autoria, também restou certa. Com efeito, foi abordada pelos policiais no local e de acordo com a versão de KARINA ela era companheira de um dos rapazes e foi ela quem as teria levado até o local que foi palco do delito de furto.

Ainda, os policiais foram firmes em dizer que apenas uma das moças confessou a prática do delito, a outra não.

Nesse aspecto, KARINA desde a delegacia negou tivesse ciência do furto e negou tenha dele participado. Em juízo manteve a mesma versão. Embora com dificuldade para se expressar, sem entrar em contradição.

Ainda, quanto à sua negativa, é certo que o policial Xu Yi Xiong teria afirmado que ela teria sido a moça a confessar o delito no dia dos fatos.

Ocorre que o depoimento fora prestado, passados mais de ano e meio da ocorrência dos fatos e a sua afirmação veio em resposta a uma pergunta formulada de forma fechada e direta o que contribui para a produção de uma falsa memória, capaz de retirar a certeza da afirmação.

Aliado a isto, está o fato de que não há prova segura nos autos de que KARINA tenha sido surpreendida na posse de um dos bens furtados.

Por fim, KARINA afirmou que conheceu os demais acusados apenas no dia e, pelo quanto restou apurado, MARIA DA PENHA e não KARINA seria a companheira de um dos rapazes.

Assim, todos esses elementos relativos a KARINA, permitem concluir que as provas não são suficientes para a sua condenação.

É certo de outro lado que KARINA afirmou que estivera em local diverso dos fatos, bebendo e curtindo e só posteriormente se dirigiu, em companhia de MARIA DA PENHA, para frente do bar onde ocorrera a empreitada criminoso.

É certo, também, que houve a tentativa de comprovar sua presença no bar Templo, mas o referido estabelecimento não possuía mais as imagens do local (fls. 536) e não foram arroladas testemunhas que estavam presentes no referido Bar Templo a fim de confirmar sua versão.

Tais elementos poderiam vir em reforço da tese defensiva. Sua ausência entretanto, não implica na alteração da conclusão em relação à acusada KARINA, porquanto, a prova do cometimento do delito por parte KARINA, incumbia à acusação, tendo a versão da sua defesa por si e analisada em conjunto com os depoimentos dos policiais, com as particularidades acima apontadas, sido suficientes para gerar dúvida quanto à participação de KARINA no delito.

Suas declarações, portanto, e sobretudo diante das demais provas reunidas nos autos, foram suficientes para por em dúvida o conjunto probatório erigido contra a sua pessoa.

Em relação aos demais réus, DANILO, ALEX SANDRO e MARIA DA PENHA, diversamente, os depoimentos colhidos, são harmônicos, e corroboram a versão de ambos os policiais militares, sendo suficientes para a condenação.

Ademais, é de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento firme em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando em decorrência da análise dos demais elementos de prova ou quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais. Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu de atendimento a solicitação via COPOM, sem que haja qualquer indício que qualquer perseguição pelos policiais houvesse em relação aos acusados.

Confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Há que se ressaltar ainda que não fossem só os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares apontando para a autoria delitiva dos acusados DANILO, ALEX SANDRO e MARIA DA PENHA, infere-se que os réus foram flagrados juntos evadindo-se em posse dos bens subtraídos logo após o crime, o que reforça mais ainda os elementos de autoria delitiva do crime de furto erigidos nos autos.

Veja-se ademais que já se pacificou na jurisprudência que sendo os acusados flagrado em posse da res furtiva, opera-se inversão do ônus da prova em seu desfavor, incumbindo aos réus apresentarem justificativa plausível para a posse do objeto, sem o que a presunção transmuda-se em certeza da autoria delitiva do crime de furto, sobretudo considerando que foram abordados em posse do bem logo após a ocorrência da subtração.

Nesse mesmo sentido, destaco recente julgado proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Furto qualificado - Prisão na posse da res furtiva logo após o crime - Álibi não comprovado - Circunstâncias que sugerem a autoria do furto - Confissão informal confirmada pelos policiais - Desclassificação para receptação - Impossibilidade; Furto qualificado - Rompimento de obstáculo - Emprego de violência contra o objeto da subtração - Qualificadora bem configurada; Furto qualificado - Simples admissão da posse Confissão - Inocorrência - Aplicação das Súmulas nº 244 e 231 do Col. Superior Tribunal de Justiça - Valor do prejuízo - Irrelevância - Crime contra o patrimônio - Pena reajustada - Réu tecnicamente primário - Regime aberto - Registros de antecedentes que autorizam concluir pelo desvio de personalidade - Substituição da pena - Inviabilidade - Recurso parcialmente provido." (TJSP - Apelação Criminal 1501421-92.2019.8.26.0548; Relator (a): Alexandre Almeida; 8ª Câmara de Direito Criminal; Julgado em 06/02/2020) (Grifei).

O concurso de pessoas também veio devidamente comprovado nos autos, seja pela análise das provas nos autos e ainda pela narrativa das testemunhas que afirmaram terem encontrado os acusados no local.

Com efeito, já se pacificou que para a caracterização do concurso de pessoas não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos.

No caso em questão, evidenciou-se que ALEX SANDRO e DANILO entraram no estabelecimento, enquanto MARIA DA PENHA compareceu ao local para auxiliar na fuga na posse dos bens furtados.

A escalada e o rompimento de obstáculo também se encontram devidamente comprovados pelos laudos periciais de fls. 393/397 e 398/408, conclusivo este último, no sentido de que "Baseado em informes e vestígios observados no local, pode-se inferir que o acessou (sic) deu-se por escalada até o balcão na Rua Marde de Deus e subsequente arrombamento da porta balcão do andar superior. Indivíduo(s) ainda teria(m) arrombado o caixa, no piso inferior (térreo) e subtraído caixa de uísque e, na fuga pelo mesmo caminho de entrada, teriam derrubado uma garrafa no passio (sic) público."

Ora, diante das provas colhidas, mostra-se, pois, suficiente à condenação dos acusados DANILO, ALEX SANDRO e MARIA DA PENHA os elementos coligidos durante a instrução, ao contrário do alegado pelas respectivas Defesas.

Não há que se falar, outrossim, na forma tentada, uma vez que os agentes executaram todo o núcleo do tipo penal, com a inversão da posse sobre os bens subtraídos, tendo sido surpreendidos quando já estavam deixando o local.

Caracterizada a infração penal, passo a dosar as penas.

1) ALEX SANDRO DOS SANTOS

Sua Folha de Antecedentes (fls. 40/44, 89/95, 186/192) e a Certidão do Distribuidor Criminal (fls. 132/134) foram juntadas aos autos.

O réu possui duas condenações anteriores transitadas em julgado (autos nº 0037119-74.2002.8.26.0050 da 28ª Vara Criminal de São Paulo – transito em julgado para a defesa em 09/02/2005; e autos nº 0098016-09.2018.8.26.0050 da Vara Regional Sul de Viol. Dom. E Fam. Cont. Mulher – transito em julgado para a defesa em 17/10/2018), assim sendo uma delas, a decorrente dos autos nº 0098016-09.2018.8.26.0050 será tida como reincidência e analisada na segunda fase da dosimetria.

A outra condenação, será aqui tida como Maus Antecedentes. Veja-se ademais que o crime foi cometido mediante duas qualificadoras no caso em tela, quais sejam, o concurso de pessoas e o fato de que o crime fora cometido mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Portanto, enquanto o rompimento de obstáculo será utilizada para tipificar o crime na forma qualificada e o concurso de pessoas será utilizado como circunstância judicial na primeira fase, uma vez que não corresponde à circunstância agravante dispostas no artigo 61 do Código Penal, conforme estabelece o STJ:

"Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante" (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 – sem grifo no original)".

Dessa forma, a pena-base deve ser exasperada em 1/5, resultando em 2 anos 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar a reincidência do réu, devendo a pena ser aumentada em mais 1/6, perfazendo 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não há que se considerar causas de aumento nem de diminuição da pena que fixo em definitivo em 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa.

2) DANILO DIAS ROCHA

Sua Folha de Antecedentes (fls. 62/72, 97/106 e 196/205) e a Certidão do Distribuidor Criminal (fls. 135/137) foram juntadas aos autos.

O réu possui duas condenações anteriores transitadas em julgado (autos nº 0001149-81.2014.8.26.0635 da 22ª Vara Criminal de São Paulo – transito em julgado para a defesa em 09/12/2015; e autos nº 0091984-32.2011.8.26.0050 7ª Vara Criminal de São Paulo – transito em julgado para a defesa em 06/12/2012), assim sendo uma delas, a decorrente dos autos nº 0001149-81.2014.8.26.0050 será tida como reincidência e analisada na segunda fase da dosimetria.

A outra condenação, será aqui tida como Maus Antecedentes. Veja-se ademais que o crime foi cometido mediante duas qualificadoras no caso em tela, quais sejam, o

concurso de pessoas e o fato de que o crime fora cometido mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Portanto, enquanto o rompimento de obstáculo será utilizada para tipificar o crime na forma qualificada e o concurso de pessoas será utilizado como circunstância judicial na primeira fase, uma vez que não corresponde à circunstância agravante dispostas no artigo 61 do Código Penal, conforme estabelece o STJ:

"Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante" (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 - sem grifo no original)".

Dessa forma, a pena-base deve ser exasperada em 1/5, resultando em 2 anos 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar a reincidência do réu, desse modo a pena deve ser aumentada em mais mais 1/6, perfazendo 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não há que se considerar causas de aumento nem de diminuição de pena que fixo em definitivo em 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa.

3) MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS

Sua Folha de Antecedentes (fls. 45/61 e 109/126) e a Certidão do Distribuidor Criminal (fls. 140/144) foram juntadas aos autos.

A ré é multirreincidente, já que possui as seguintes condenações anteriores transitadas em julgado (autos nº 0024484-75.2013.8.26.0050 da 20ª Vara Criminal de São Paulo, autos nº 0026930-37.2002.8.26.0050 da 15ª Vara Criminal de São Paulo, autos nº 0059115-31.2002.8.26.0050 da 21ª Vara Criminal de São Paulo, autos nº 0071989-14.2003.8.26.0050 da 7ª Vara Criminal de São Paulo), assim sendo uma delas será considerada como reincidência e analisada na segunda fase de aplicação e as demais, como maus antecedentes, por outro lado, considerando a incidência de duas qualificadoras, uma delas também será aqui reconhecida como circunstância do crime e portanto, a pena base será aumentada em 2/3 já que não lhe favorecem as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, chegando-se ao patamar de 3 anos, 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar a reincidência da ré, desse modo a pena deve ser aumentada em mais 1/6, chegando-se na quantia de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

Na terceira fase, não há que se considerar causas de aumento nem de diminuição de pena que fixo em definitivo em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de condenar como incursos no art. 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal, ALEX SANDRO DOS SANTOS, aplicando ao réu a pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa, no mínimo legal, já que não há nos autos provas das condições financeiras do acusado; DANILO DIAS ROCHA aplicando ao réu a pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa, também no mínimo legal, porque não há comprovação de sua situação financeira; e MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS aplicando á ré a pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 18 dias-multa, também no mínimo legal, porque não há comprovação de sua situação financeira; e, ainda, JULGO IMPROCEDENTE a ação a fim de ABSOLVER a acusada KARINA DE OLIVEIRA SILVA da imputação de ter cometido o crime do art. 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena dos acusados ALEX SANDRO DOS SANTOS, DANILO DIAS ROCHA e MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS deverá ser o fechado, tendo em vista a reincidência dos réus, bem como as circunstâncias judiciais que lhes desfavorecem.

Deixo de computar o período de prisão provisória dos réus para determinar o regime

inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente em critério objetivo. Depende, também, do mérito do condenado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos parte da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Além disso, prevalecer o entendimento de que a lei não determina o cômputo do período de prisão provisória como meio de antecipar a progressão de regime, mas como critério para fixar o regime inicial de cumprimento da pena, aquele que sob custódia esteve no curso do processo poderá ser agraciado com progressão, na fase de execução criminal, com novo desconto do período já considerado para beneficiá-lo com regime menos gravoso na sentença condenatória.

Faz-se mister destacar a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal, haja vista a reincidência dos réus ALEX SANDRO DOS SANTOS, DANILO DIAS ROCHA e MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS, bem como porque tal benefício não lhes é suficiente. Sendo também inviável a aplicação do sursis, consoante disposto no art. 77, I, também do CP.

Como é sabido, não basta que o acusado satisfaça os requisitos objetivos da lei para ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, é necessário, também que os requisitos subjetivos lhe sejam favoráveis. Nesse sentido, a jurisprudência: “Eventual substituição da pena de privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a estipulação de regime prisional, estão a depender da análise articulada das circunstâncias subjetivas dos pacientes, as quais, in casu, foram inteiramente desfavoráveis”.

Concedo o direito de recurso em liberdade aos acusados LEX SANDRO DOS SANTOS, DANILO DIAS ROCHA e MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS, uma vez que responderam ao processo em liberdade e não sobrevieram motivos que determinassem a sua custódia cautelar.

Havendo recurso de uma das partes, expeça-se guia de execução provisória, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA